

1501121-06.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501121-06.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2193208/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 19094470 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1971/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2193208 - 02º D.P. PIRACICABA, 1971/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DA SILVA DOMINGUES

Vítima:

ESCOLA ESTADUAL MELLO COTRIM

Artigo da Denúncia:

*

Aos 03 dias do mês de março de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Rafael Augusto Pressuto e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) LUCAS DA SILVA DOMINGUES, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Guilherme dos Santos, Alessandro Félix da Silva Quadros e Marise do Amaral Campos Cílio. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram)

colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Guilherme, Alessandro, Marise) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

LUCAS DA SILVA DOMINGUES foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso II, cc. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pois, no dia 21 de março de 2021, por volta de 04h20min, nas dependências da “EE Prof. Antonio de Mello Cotrim”, situada na Rua Dona Stella, n.º 65, Bairro Paulicéia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, durante o período de repouso noturno, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada, 01 (um) bola de vôlei da marca Kaemy, avaliada em R\$ 90,00 (noventa reais), 02 (duas) bolas de futebol da marca Penalty, avaliadas em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), e 50 (cinquenta) metros de perfil em alumínio, avaliados em R\$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), pertencentes à “Escola Estadual Prof. Antonio de Mello Cotrim”, representada por Marise do Amaral Campos Cillo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O processo teve andamento regular.

A denúncia foi recebida a fls. 126/127. Devidamente citado a fls. 135, o réu apresentou resposta à acusação a fls. 139/143. Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas.

É a síntese do necessário.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 14/15, auto de avaliação de fls. 18/19, laudo pericial de fls. 184/189, bem como pelas provas colhidas em juízo.

Autoria por parte do acusado também restou devidamente comprovada.

O policial militar Guilherme dos Santos, ouvido na repartição policial, relatou:

“Foi acionado via copom para atender ocorrência versando sobre furto em andamento na escola Mello Cotrim, sendo que o autor estaria andando pelo telhado do estabelecimento de ensino. O policial afirma que se dirigiu ao local indicado para averiguar a denúncia. O policial afirma que chegou na escola em questão e, de pronto, viu algumas bolas e ferros já na parte externa, os quais já estavam separados para serem levados. Segundo o policial, na sequência, um indivíduo, ora indiciado, pulou um muro da escola para acessara via pública. O policial afirma que tal indivíduo estava na posse de mais ferros subtraídos da escola. O policial afirma que, ao visualizar a viatura, o implicado tentou fugir mas foi detido rapidamente. Por fim, o policial afirma que, de maneira informal, o implicado confessou que havia subtraídos os objetos da escola em comento” (fls. 02).

Em juízo, o policial confirmou os fatos narrados na fase administrativa. Relatou que, no dia dos fatos, foi acionado para atender ocorrência de furto em andamento na escola em questão. Ao chegar ao local, visualizaram alguns objetos esportivos e alumínio do lado de fora do estabelecimento. O acusado, então, tentou pular do lado de dentro para fora da escola, quando foi abordado e detido. O réu, na oportunidade, confessou que furtava para comprar drogas. O acusado pulou um muro da escola. Informou que, no interior da escola, constatou que a porta onde ficam os objetos esportivos estava arrombada, sendo certo, ainda, que o alumínio que prende as partes de cima do telhado também estava danificado. Na ocasião, o acusado disse que pulou o muro para furtar as peças. Disse que as bolas furtadas estavam no quarto em que a porta havia sido arrombada.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Alessandro Felix da Silva Quadros, tanto na Delegacia de Polícia (fls. 03), quanto em juízo.

A representante da vítima, Marise do Amaral Campos Cillo, ouvida em solo policial, relatou: “não presenciou os fatos e compareceu neste plantão policial para retirada e responsabilidade dos objetos apreendidos e entregues conforme auto de exibição, apreensão e entrega” (fls. 04).

Em juízo, a representante da vítima disse que, no dia dos fatos, foi chamada pelo

caseiro da escola, que havia visto um rapaz pulando o muro com objetos da escola. Quando chegou ao local, os policiais já haviam chegado e o acusado estava detido. Então, recebeu os bens que haviam sido furtados. Informou que o acusado tentou subtrair um para raio e algumas bolas. O para raio foi retirado do local e as bolas estavam em um quarto, cuja porta foi arrombada. Informou que esta porta havia sido arrombada anteriormente, mas havia sido consertada e, no dia dos fatos, estava devidamente trancada, sendo novamente arrombada.

Interrogado em sede policial, o réu exerceu seu direito de permanecer em silêncio quantos aos fatos (fls. 05).

Em juízo, o acusado confessou parcialmente a prática do crime, dizendo que tentou subtrair apenas o alumínio. Afirmou que, para entrar na escola, pulou o muro do imóvel.

Malgrado a versão apresentada pelo acusado, as provas conduzem à segura convicção acerca da prática delitativa, da forma narrada na denúncia.

Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais militares são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela.

Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: "O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". Ainda nesse sentido: "PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido" (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei).

Demais disso, o painel probatório confirma a qualificadora da escalada, bem como a circunstância do repouso noturno, conforme relatado pelo representante da vítima e testemunhas.

Assim, o delito em comento continua qualificado pelo inciso II, do § 4º do art. 155 do Código Penal.

Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor.

No que tange à dosimetria da pena, observo que o acusado ostenta péssimos antecedentes criminais, razão pela qual a sanção básica deve ser fixada acima do mínimo legal (fls. 52/73 e 74/81).

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, conforme certidões de fls. 74/81, devendo a pena dos acusados ser majorada.

Já na terceira fase de dosimetria da pena, incide a causa de aumento de 1/3 (um terço) referente ao repouso noturno, estampada no § 1º do art. 155, do CP.

Considerando que o crime foi tentado, entendo que a reprimenda deva ser reduzida em 1/3, considerando o iter criminis percorrido, uma vez que os bens já estavam separados do lado externo da escola.

Outrossim, a quantidade da pena a ser fixada, bem como a as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado impõem a fixação inicial do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal, vedada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou "sursis".

Ante o exposto, aguardo a procedência da denúncia, com a condenação do réu LUCAS DA SILVA DOMINGUES nos moldes pleiteados.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, Lucas da Silva Domingues foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, c. c/ artigo 14, inciso II, do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 124-125), no dia 21 de março de 2021, por volta de 04h20, nas dependências da "EE Prof. Antônio de Mello Cotrim", situada na Rua Dona Stella, n.º 65, Bairro Paulicéia, nesta cidade e comarca de Piracicaba, Lucas, durante o período de repouso noturno, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada, 01 (um) bola de vôlei da marca Kaemy, avaliada em R\$90,00 (noventa reais), 02 (duas) bolas de futebol da marca Penalty, avaliadas em R\$180,00 (cento e oitenta reais), e 50 (cinquenta) metros de perfil em alumínio, avaliados em R\$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), pertencentes à "Escola Estadual Prof. Antoni de Mello Cotrim", representada por Marise do Amaral Campos Cillo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda de acordo com a inicial, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, Lucas se dirigiu ao estabelecimento escolar para furtar objetos. Após transpor - mediante escalada - os muros e obstáculos que cercam o bem público, passou a se apoderar de bolas esportivas e adornos de alumínio fixados no imóvel. Ocorre que Lucas teve sua ação interrompida por policiais militares acionados ao local. Nesse instante, já na parte externa da escola, abandonou parte dos objetos que havia separado e tentou fugir pulando muros. Mesmo assim, ainda na posse de peças em alumínio, foi detido pelos militares (fls. 02 e 03). Os materiais foram recuperados e restituídos ao representante (fls. 04 e foto fls. 14/17). O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, quais sejam, a comunicação anônima à Polícia Militar e a pronta intervenção dos agentes policiais.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu exerceu o direito constitucional ao silêncio (fls. 5).

Em solo policial, Marise do Amaral Campos Cillo, diretora escolar/representante, disse que: "não presenciou os fatos e compareceu neste plantão policial para retirada e responsabilidade dos objetos apreendidos e entregues conforme auto de exibição, apreensão e entrega" (fls. 4).

Guilherme dos Santos, policial militar, narrou que: "foi acionado via COPOM para atender ocorrência versando sobre furto em andamento na escola Mello Cotrim, sendo que o autor estaria andando pelo telhado do estabelecimento de ensino. Dirigiu-se ao local indicado para averiguar a denúncia. Chegou na escola em questão e, de pronto, viu algumas bolas e ferros já na parte externa, os quais já estavam separados para serem levados. Na sequência, um indivíduo, ora indiciado, pulou um muro da escola para acessara via pública. Tal indivíduo estava na posse de mais ferros subtraídos da escola. Ao visualizar a viatura, o implicado tentou fugir, mas foi detido rapidamente. De maneira informal, o implicado confessou que havia subtraídos os objetos da escola em comento" (fls. 2).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Alessandro Felix da Silva Quadros (fls. 3).

As fls. 74-81, certidão de objeto e pé que indica os maus antecedentes (autos n.º 0012348-17.2010.8.26.0320 - furto qualificado - trânsito em julgado para a Defesa em 23/7/2012) e a reincidência do requerido (autos n.º 0000138-60.2012.8.26.0320 - furto qualificado - pena extinta em 28/2/2018; autos n.º 1500285-51.2019.8.26.0551 - furto qualificado - trânsito em julgado para a Defesa em 03/12/2019; autos n.º 0002792-20.2012.8.26.0320 - furto qualificado - pena cumprida ou julgada extinta em 1/3/2018; autos n.º 0012706-45.2011.8.26.0320 - furto qualificado - pena cumprida ou julgada extinta em 1/3/2018; autos n.º 0017687-54.2010.8.26.0320 - furto qualificado - pena cumprida ou julgada extinta em 28/2/2018; autos n.º 0022662-22.2010.8.26.0320 - furto qualificado - pena cumprida ou julgada extinta em 1/3/2018).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelos autos de exibição e apreensão de fls. 14-15, fotografia de fls. 16 e 17, auto de avaliação de fls. 18-19, laudo de exame do local dos fatos de fls. 184-189 que indica a presença de vestígios. Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, foi ouvido Guilherme dos Santos, policial militar. Relata que foram acionados para ocorrência na escola Mello Cotrim. Ali chegando, viram o indivíduo pulando o muro de dentro para fora da escola. Abordado, o indivíduo confessou os fatos. Informalmente, confessou que estava furtando para sustentar o vício. Ao chegarem, viram objetos separados no pátio da escola e outros já estavam do lado de fora da escola. Após deter o indivíduo, entraram na escola para ver se algo mais tinha sido furtado. Uma pessoa, acha que o zelador, abriu o portão para entrarem. Viu bolas e peças de alumínio. As peças de alumínio são do telhado, usadas para fixar as telhas. Provavelmente o indivíduo retirou essas peças do telhado. Acredita que o réu entrou no lugar pulando o muro. Não conhecia o réu. Quanto à porta supostamente arrombada, esclareceu que as bolas estavam no cômodo acessado por ela. O réu nada disse sobre ter arrombado a porta.

c) Ouvido o policial militar Alessandro Felix da Silva Quadros. Recebeu a informação via COPOM de um furto em andamento, sendo que o indivíduo estava sobre o telhado. Chegando na escola, viram bolas e pedaços de ferro separados na calçada, do lado de fora da escola. O indivíduo tentava pular o muro para fora da escola. Interceptaram-no e, informalmente, ele confessou o delito e disse que iria vendê-los para comprar drogas. Depois da prisão, ingressaram na escola. O zelador, que foi quem acionou a polícia, abriu o portão. O parceiro subiu no telhado e viu que os metais eram pedaços de calha usados nessa estrutura. As bolas estavam guardadas em um quartinho próximo à quadra de futebol da escola. Foram retiradas pelo réu desse quartinho. Não sabe dizer se a porta do quartinho estava arrombada daquele dia ou de dias anteriores, pois várias vezes a escola passou por furtos.

c) Em seguida, foi ouvida Marise do Amaral Campos Cillo, diretora escolar/representante. Foi chamada pelo caseiro porque um furto estava ocorrendo. Não era o primeiro furto. Quando chegou na escola, estava a pessoa detida e os policiais. Foi à delegacia para que pudesse retirar os bens apreendidos em posse do réu. Os bens eram: um para-raios que o réu estava enrolando e algumas bolas. O para-raios foi retirado de cima do telhado. As bolas ficavam em um quartinho próximo da quadra. A porta desse local foi arrombada nesse dia também. Já tinha sido arrombada antes e a porta foi arrumada, e nessa noite foi novamente arrombada. Conseguiu recuperar os bens, mas estavam danificados. O prejuízo da escola, na ocasião, foi pesquisado na delegacia juntamente da escrivã e constou do boletim de ocorrência.

d) Por fim, foi interrogado o réu Lucas da Silva Domingues. Sobre os fatos, confirma que tem diversas passagens por furto. Não foi o responsável pela tentativa de subtração das bolas. Mas confessa que tentou levar peças de metal. Chegou até a pegar torneiras do bebedouro, mas nem perceberam. Levou no ferro-velho. Sempre furta objetos de metal para vender no ferro-velho. Quanto às bolas, não foi ele. Ingressou a escola pulando o muro e andou sobre o telhado. Entrou no quartinho e mexeu no armário. Viu bolas e jogos, mas achou que não era de seu interesse. Chegou a dizer para os amigos que havia esses objetos lá, eles podem ter sido os responsáveis por mexer nas bolas, mas não foi ele. Chegou a levar um amigo junto, mas ele desistiu. Não arrombou a porta do quartinho. Se ele quisesse arrombar algo, teria entrado na escola e pegado a TV ou as caixas de som. Nesse dia, entrou 3 ou 4 vezes na escola, levou diversas viagens de ferro, pegou estruturas de cadeiras, ralos etc. Não viu se alguém entrou junto, mas já viu em outras ocasiões pessoas aproveitarem que estão mexendo e entrar também.

- DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA

Tendo em vista que os bens subtraídos foram restituídos à representante da escola, o caso é de absolvição por atipicidade material da conduta, em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse contexto, de início, saliente-se que insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, como afirma, a propósito, Paulo Queiroz:

“O princípio da insignificância constitui, portanto, um instrumento por cujo meio o juiz, em razão da manifesta desproporção entre crime e castigo, reconhece o caráter não criminoso de um fato que, embora formalmente típico, não constitui uma lesão digna de proteção penal, por não traduzir uma violação realmente importante ao bem jurídico tutelado” (Direito penal: parte geral, v. 1. 13. ed. Salvador: Juspodivm,

2018, p. 91).

Dinamizando a incidência da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, fixou o entendimento sobre a necessidade da verificação de quatro pressupostos para sua aplicação: a) a pequena ofensividade da conduta do agente; b) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) nenhuma periculosidade social da ação; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada:

"E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R\$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social." (HC 84412, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. em 19/10/2004).

Este julgado tornou-se o verdadeiro leading case da matéria e vem sendo reiterado por inúmeras decisões, tanto do próprio Supremo Tribunal Federal, quanto deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes: a) no STF: HC 97129/RS, Min. Rel. Eros Grau; HC 97189/RS, Min. Rel. Ellen Gracie; STF, HC 96496/MT, Min. Rel. Eros Grau; HC 105974, Min. Rel. Ayres Britto; HC 93393, Min. Rel. César Peluso; HC 93453, Min. Rel. Joaquim Barbosa; b) no STJ, RHC 23.376/MG, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho; HC 198996/SC, Min. Rel. OG Fernandes; HC 34626/MG, Min. Rel. Félix Fischer; STJ, HC 18314/RJ; HC 139015/SP, Min. Rel. OG Fernandes; HC 122435/MG, Min. Rel. Celso Limongi.

Ora, a aplicação do princípio da insignificância é uma questão de política criminal, afastando a intervenção penal para delitos que, do ponto de vista jurídico-penal, são considerados menos reprováveis. E, ao fazê-lo, permite-se que o poder punitivo seja exercido de forma mais enérgica em relação aos delitos que, efetivamente, atentam contra a paz social.

Saliente-se, ainda, que o reconhecimento da insignificância não irá causar qualquer desamparo à vítima. Pelo contrário, o que se postula é que seja reconhecida a insignificância do ponto de vista jurídico-penal. Ou seja, o que se requer é o afastamento das consequências jurídico-penais. Com isso, a vítima, caso entenda que tenha sofrido algum tipo de prejuízo, ainda poderá pleitear a devida reparação na esfera civil, eis que a sentença que reconhece a atipicidade da conduta não produz coisa julgada na esfera extrapenal (CPP, art. 67, III). Percebe-se, dessa forma, que somente se justificaria manter a persecução penal para assegurar à vítima um

título executivo judicial, eis que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar (CP, art. 91 c. c/ CPC, art. 515, VI). Todavia, é necessário separar as esferas penal e civil e, assim, retiradas as consequências jurídico-penais da conduta, não se justifica a manutenção do processo penal, seja por causa dos inúmeros gravames que serão causados ao imputado, seja pelo fato que os interesses da vítima – meramente econômicos – ainda estarão amparados pelo ordenamento.

Se é assim, impõe-se a absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a agravante da reincidência deverá ser compensada com a atenuante da confissão, ainda que seja apenas a informal, mantendo-se a pena no mínimo legal.

c) Da tentativa

Na terceira etapa de dosimetria de pena, conforme se infere dos elementos de prova produzidos em juízo, o acusado esteve muito distante da consumação: logo após dar início à subtração, ele foi surpreendido pelos policiais que impediram a consumação do delito.

Assim, a minorante do art. 14, II, do Código Penal deve ser aplicada em seu patamar máximo.

d) Do repouso noturno

Na terceira etapa de dosimetria de pena, é de rigor o afastamento da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º).

Isso porque, conforme se infere da redação do § 1º do art. 155 do Código Penal, é imprescindível a perturbação do repouso noturno, o que não se pode considerar ter ocorrido, tendo em vista que a suposta subtração se deu em estabelecimento escolar que se encontrava fechado.

É o que entende a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Não obstante, deve ser afastada a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal (crime praticado durante o repouso noturno), pois para que seja configurada esta causa, não basta que o furto ocorra no período noturno, mas que a vítima se encontre em repouso no local furtado, o que não ocorreu no caso presente, pois o veículo estava estacionado na via pública. Nesse sentido:

'Predomina em nossos pretórios o entendimento de que a agravante especial de furto noturno só pode ser reconhecida quando a ação ocorre em casa habitada, cujos moradores estejam repousando. Incabível tal reconhecimento por ter sido cometido contra estabelecimento comercial' (TACRIM-SP AC Rel. Maíra Carbonieri RJD 6/97);

'Impõe-se, no entanto, a exclusão da majorante do furto noturno, pois demonstrado nos autos que a ação ocorreu na via pública, não se podendo cogitar, portanto, de 'repouso noturno', como exige o dispositivo. Nesse sentido, já se decidiu que, 'para que se caracterize a qualificadora do repouso noturno, é necessário que o furto seja perpetrado em casa habitada, cujos moradores estejam dormindo' (RJD 25/191, rel. Junqueira Sangirardi), bem como que 'para o reconhecimento da agravante do art. 155, § 1º, do CP, é necessário que o furto seja praticado em casa habitada, onde haja alguém repousando. Deste modo, o furto de veículo em via pública não enseja a aplicação da majorante do furto noturno' (RT596/410)' (Apelação Criminal nº 0079341-95.2018.8.26.0050, Rel. Des. Vico Mañas, j. em 03.04.2019)”. (Apelação criminal 1500872-89.2020.8.26.0599, Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, j. em 08.02.2022)

Sendo assim, mostra-se de rigor o afastamento da majorante do art. 155, § 1º, do Código Penal, eis que não ocorreu a “perturbação do repouso noturno”.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que as requeridas responderam ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

LUCAS DA SILVA DOMINGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 21 de março de 2021, por volta de 04h20, nas dependências da "EE Prof. Antônio de Mello Cotrim", situada na Rua Dona Stella, n.º 65, Bairro Paulicéia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, durante o período de repouso noturno, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada, 01 (um) bola de vôlei da marca Kaemy, avaliada em R\$90,00 (noventa reais), 02 (duas) bolas de futebol da marca Penalty, avaliadas em R\$180,00 (cento e oitenta reais), e 50 (cinquenta) metros de perfil em alumínio, avaliados em R\$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), pertencentes à "Escola Estadual Prof. Antônio de Mello Cotrim", representada por M.A.C.C. não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo a denúncia, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, Lucas - que de longa data se dedica à prática de delitos patrimoniais - se dirigiu ao estabelecimento escolar para furtar objetos.

Após transpor - mediante escalada - os muros e obstáculos que cercam o bem público, passou a se apoderar de bolas esportivas e adornos de alumínio fixados no imóvel. Ocorre que Lucas teve sua ação interrompida por policiais militares acionados ao local. Nesse instante, já na parte externa da escola, abandonou parte dos objetos que havia separado e tentou fugir pulando muros.

Mesmo assim, ainda na posse de peças em alumínio, foi detido pelos militares (fls. 02 e 03). Os materiais foram recuperados e restituídos ao representante (fls. 04 e foto fls. 14/17).

Na delegacia, o réu ficou silente (fls. 05).

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, quais sejam, a comunicação anônima à Polícia Militar e a pronta intervenção dos agentes policiais. A denúncia foi recebida (fls. 126/127), o réu foi citado (fls. 135), apresentando resposta escrita, na qual requereu a concessão de liberdade provisória e alegou inocência (fls. 139/143).

O recebimento da denúncia foi mantido, concedendo a liberdade provisória e designando audiência (fls. 149/152).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, e 02 testemunhas em comum, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de apreensão e entrega de fls. 14/15, pelas fotografias de fls. 16/17, pelo auto de avaliação de fls. 18/19, segundo o qual a res foi avaliada em R\$ 1.420,00.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu.

Durante a fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05).

Em Juízo, o réu disse que subtraiu o alumínio do telhado, que iria vender no ferro-velho, para comprar droga. Não foi ele quem furtou as bolas. Entrou na escola pulando o muro. Chegou a pegar torneiras do bebedor, mas era de plástico. Chegou a

levar também ralos pesados, mas não bolas. Já tinha entrado na escola outras vezes. Chegou a entrar no quartinho, mas não quis pegar, porque achou que não iria te dar dinheiro. Chegou a levar um bebedouro. Pode ser que amigos tenham pegado as bolas, mas não ele. Chegou a levar um amigo seu, mas ele ficou com medo e só ele entrou na escola. O quartinho estava aberto, não chegou a arrombar essa porta. Se tivesse arrombado a porta, poderia ter ingressado na escola e pegado a TV e o aparelho de som, que tinham valor maior. Chegou na escola por volta de 1h00. Chegou com o amigo, mas ele não quis entrar. Não sabe se ele ficou fora ou se ele foi embora. Fez de 03 a 04 viagens da escola para o ferro-velho. Fez um feixe com o ferro de carteiras escolares e levou para vender. Não viu mais ninguém dentro da escola, não viu mais ninguém.

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída ao réu. Vejamos.

A representante da vítima M.A.C.C. declarou que é diretora da escola. Foi chamada pelo caseiro, Sr. Euclides, que tinha visto o rapaz pulando o muro, com algumas coisas da escola. Ele chamou os policiais. Quando chegou na escola, estavam os policiais e o réu. Precisava ir com os policiais à Delegacia, para que pudesse recuperar os bens. Tinham sido retirados o para raio, algumas bolas. O para raio tinha sido retirado do telhado. As bolas ficavam num quartinho na quadra. Essa porta do quartinho tinha sido arrombada. Conseguiu recuperar aos objetos. Não teve o que fazer com o para raio, porque estava danificado. Na ocasião, fez um cálculo de qual era seu prejuízo, mas quando fizeram o boletim de ocorrência, a escritã pesquisou junto com ela o preço para refazer o para raio.

Inquisitivamente, a representante da vítima M.A.C.C. declarou que não presenciou os fatos e compareceu ao Plantão Policial para retirada dos objetos apreendidos e entregues conforme auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 04).

O policial militar Guilherme dos Santos relatou que foram acionados para ocorrência de furto na escola. Ao chegar ao local, ainda do lado de fora, na calçada, havia objetos esportivo e peças de alumínio e ferro. O réu não visualizou os policiais e pulou o muro do lado de dentro para o lado de fora e, por isso, foi abordado. Ele disse que estaria furtando, para comprar drogas. Depois de deter o réu, adentraram à escola, porque uma pessoa que toma conta da escola abriu o portão. A porta de onde ficavam os objetos esportivos estavam arrombados e a parte de cima do telhado de onde os aluminios tinham sido retirados, estava mexido. Acredita que o réu tenha entrado pulando o muro. O réu disse que tinha pulado para pegar as peças. Não conhecia o réu. Os objetos esportivos estavam no cômodo, cuja porta tinha sido arrombada. O réu não disse que tinha arrombado a porta.

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Alessandro Felix da Silva Quadros, que afirmou que o Copom avisou de furto em andamento pela escola. Chegando ao local, viram bolas, pedaços de ferro e alumínio do lado de fora, na calçada.

Nesse momento, o réu pulou de dentro para fora da escola, com mais pedaços de ferro, e foi abordado. O réu confessou que estava furtando para usar drogas. Ingressaram na escola, porque o rapaz que mora lá abriu o portão. No interior da escola, seu parceiro subiu no telhado, de onde o réu tinha retirado os aluminios e ferro das calhas. Perto da quadra de futebol, dentro da escola, tinha um quartinho, de onde as bolas tinham sido retiradas. A porta do quartinho estava arrombada, mas não sabe se foi em razão desse furto, porque está havendo muitos furtos nessa escola. Seu parceiro entrou primeiro e ele ficou de guarda do preso e da viatura. Os fatos ocorreram de madrugada.

Com efeito, a autoria restou comprovada nos autos em relação ao réu.

O réu não apresentou versão dos fatos, na fase policial e, em Juízo, confessou que ingressou na escola e subtraiu os ferros e aluminios, mas não as bolas.

A representante da vítima não presenciou os fatos, apenas foi à Delegacia para retomar os bens que o réu tentou subtrair.

Os policiais militares narraram que foram acionados para atender ocorrência sobre furto em andamento na escola Mello Cotrim. Logo que chegaram ao local, observaram algumas bolas e ferros já separados na parte externa da escola, na calçada. Na sequência, o réu pulou o muro da escola para acessar a via pública, na posse de mais ferros subtraídos da escola. Ao visualizar a viatura, ele tentou fugir, mas foi detido. Informalmente, o réu confessou a autoria.

Nesse sentido, o réu foi avistado pelos policiais pulando o muro da escola, de dentro para fora, depois de já ter separado a res.

Essa situação fática confirma a autoria delitiva.

De mais a mais, o réu pulou o muro na posse de parte da res, o que, por si só, já faz presumir-se a autoria, cabendo ao próprio acusado a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

APELAÇÃO DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉUS CONFESSOS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE

DESCCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. "MUTATIO LIBELLI". FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (...) 2. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). (...) (TJSP; Apelação 0042098-25.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).

APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. "RES" ENCONTRADA NA POSSE DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. ATIPICIDADE MATERIAL EM DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. (...) 3. A apreensão das "rei" em poder dos acusados acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhes a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Precedentes do TJSP. (...) (TJSP - Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Jaú; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 03/02/2016; Data de registro: 04/02/2016).

"Agente encontrado na posse da res furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de responsabilidade somente afastável mediante produção de prova consistente" (TACRIM - SP - AC - Rel. Renato Nalini - RT 719/458).

No caso dos autos, o réu se manteve em silêncio na fase inquisitiva e confessou, em Juízo, de forma que a presunção se tornou certa.

3) Da qualificadora da escalada

Neste momento, cabe perquirir sobre a qualificadora de escalada ou destreza.

A fotografia de fls. 186 evidencia que o muro era alto e, portanto, o agente precisou de especial habilidade para transpô-lo.

Sobre o arrombamento, a denúncia não o descreveu e, ainda que assim não fosse, a prova não foi suficiente para se identificar que foi o réu o seu autor. Embora os policiais tenham avistado bolas na calçada da escala, o fato é que o réu disse que ingressou na sala esportiva, no entanto, não subtraiu de lá nenhum bem. Acrescentou que a porta já estava arrombada.

Assim, não é possível saber se a porta foi arrombada pelo réu ou por terceira pessoa, até mesmo pelo informado pelo policial Alessandro, no sentido de que outros furtos já tinham ocorrido.

4) Da tentativa

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça adotou a teoria da apprehensio ou amotio, no sentido de que o furto de consuma com a posse do bem desde que se tenha cessado a clandestinidade.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem,

ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015). Como o réu se apossou dos bens, mas não conseguiu fazer cessar a clandestinidade, já que quando saiu da escola foi detido pelos policiais, deve ser reconhecida a figura tentada.

5) Do repouso noturno

O furto cometido durante o repouso noturno, assim reconhecido entre o período em que, naquela localidade onde os fatos ocorreram, a população costumeiramente se recolhe e desperta para a vida cotidiana, é apenado com maior rigor, uma vez que o bem jurídico tutelado está mais vulnerável.

No caso concreto, o réu efetuou o delito em uma escola, por volta das 04h30. Além disso, a diretora afirmou que o caseiro vivia na escola, ou seja, o local era habitado. Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que a escola estivesse desocupada, o fato é que o horário era de menor atenção e a res estava menor protegida, por isso, a causa de aumento deve ser reconhecida.

Sobre o assunto, assim já se manifestou Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 15ª edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2015, p. 876): "a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está em casa dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que nos parece tenha sido o objetivo da lei. Nessa visão: STJ: "Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, sendo irrelevante o fato de que o crime tenha sido cometido em estabelecimento fechado" (REsp 1.191.065-MG, 5ª T., rel. Gilson Dipp, 17.04.2012, v.u.).

Assim já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. (1) FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (2) RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA. VALIDADE. (3) TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (4) "RES" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (5) RÉU CONFESSO. (6) MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO (7) FURTO CONSUMADO. (8) DOSIMETRIA DA PENA QUE EXIGE REPARO. CERTIDÕES INIDÔNEAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CONTRADIÇÃO À SÚMULA 444, DO STJ. (9) DESDOBRAMENTO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA MERECEDORA DE REPARO, SOB O RISCO DE INTERPRETAÇÃO "IN MALAM PARTEM". (10) REGIME SEMIABERTO. (11) DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO NESTA INSTÂNCIA. (12) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) 6.2. Repouso noturno. Não se adota o critério do exato momento em que a vítima estaria dormindo, sob pena de incorrer em demasiada subjetividade e gerar enorme insegurança jurídica. Aliás, o aumento de pena atinente ao repouso noturno justifica-se não somente pela menor intensidade de vigilância por parte da vítima, mas, mormente, em relação à vigilância dada por terceiros. Outrossim, não há que se falar sobre a necessidade do imóvel ser uma residência ou estabelecimento comercial, porquanto o local em que se deu o crime é irrelevante, bastando que ele seja praticado, tão somente, durante o período de repouso noturno. Precedentes do STJ (REsp 1113558/RS - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ª T. - j. 17.06.2010 - DJe 28.06.2010 e HC 29.153/MS - Rel. Min. Gilson Dipp - 5ª T. - j. 02.10.2003 - DJe 03.11.2003). (...) 8. Provimento parcial do recurso defensivo. (TJSP - Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 22/11/2016; Data de registro:

24/11/2016).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça ensina:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.642.619 - AM (2016/0323079-0) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 03/02/2017).

[...] 2.3 INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DISPOSTA NO § 1º DO ART. 155 DO CÓDIGO. PENAL. A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena descrita no § 1º do art. 155 do Código Penal, sob alegação de que "no momento da ocorrência do suposto furto tanto as vítimas quanto as pessoas presente nas